

刑法
No120

共通問題 R2-9

(配点：2)

月 日

月 日

原因において自由な行為に関する次の各【見解】に従って後記の各【事例】における甲の罪責を検討した場合、後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。

【見 解】

- A. 責任能力がある状態で行われた原因行為を実行行為と捉える。
- B. 責任能力を欠いた状態で行われた結果行為を実行行為と捉えつつ、責任能力は意思決定時に存在すれば足り、必ずしも実行行為時に存在することは必要ない。

【事 例】

- I. 甲は、X宅に赴いて同人を殺害しようと決意し、心神喪失状態に陥る可能性があることを認識しつつ、自宅において景気づけのために覚醒剤を使用したところ、心神喪失状態に陥り、当初の計画どおりXを殺害した。
- II. 甲は、X宅に赴いて同人を殺害しようと決意し、心神喪失状態に陥る可能性があることを認識しつつ、自宅において景気づけのために覚醒剤を使用したところ、心神喪失状態に陥ったが、X宅には赴かず、Xの殺害には及ばなかった。
- III. 甲は、覚醒剤を使用すると粗暴になり周囲に暴行を加える習癖があると知りつつ、覚醒剤を使用した結果、心神喪失状態に陥り、Xと口論になり、殺意を生じて同人を殺害した。

【記 述】

- 1. Aの見解によれば、事例Iでは、甲に、Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。
- 2. Aの見解を採った上で、未遂犯の成立時期は結果発生の現実的な危険性が生じた段階に求められるべきで、それが常に実行行為の開始段階に認められる必然性はないと考えれば、事例IIでは、甲に、Xに対する殺人未遂罪は成立しない。
- 3. Aの見解によれば、事例IIIでは、甲に、Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。
- 4. Bの見解によれば、事例Iでは、甲に、Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。
- 5. Bの見解によれば、事例IIでは、甲に、Xに対する殺人未遂罪は成立しない。

1 正しい

Aの見解は、責任能力がある状態で行われた原因行為を実行行為と捉える見解（原因行為説）である。Aの見解によると、事例Ⅰにおける甲の覚醒剤使用行為（原因行為）が実行行為となる。その結果、当初の計画通り、乙殺害の死亡結果が発生している。そして、Aの見解によれば、構成要件該当事実の認識・予見に加えて、自己が心神喪失・耗弱状態に陥ることの予見という二重の故意が必要とされるところ、甲は、覚醒剤使用時点において、乙の殺害を決意し、かつ自己が心神喪失状態に陥るであろうことを認識していたので、故意も認められる。したがって、Aの見解によれば、事例Ⅰでは、甲に、Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。

2 正しい

Aの見解（原因行為説）を採った上で、未遂犯の成立時期は結果発生の実質的な危険性が生じた段階に求められるべきで、それが常に実行行為の開始段階に認められる必然性はないとして、「実行行為の時点」と「実行の着手時期」を区別する見解がある。この見解によると、事例Ⅱにおいて、甲が覚醒剤を使用したことが「実行行為の時点」であるが、甲はX宅には赴かず、Xの殺害には及ばなかったことから結果発生の実質的な危険性が生じた段階に至っておらず、未遂犯が成立する「実行の着手時期」には至っていない。したがって、本記述の見解からは、甲に、Xに対する殺人未遂罪は成立しない。

3 誤っている

Aの見解（原因行為説）によると、構成要件該当事実の認識・予見に加えて、自己が心神喪失・耗弱状態に陥ることの予見という二重の故意が必要とされるところ、事例Ⅲにおいて、甲は、覚醒剤使用時点において、覚醒剤を使用すると粗暴になり周囲に暴行を加える習癖があると知っていたにとどまり、乙殺害についての認識・予見を欠いているため、殺人罪の故意が認められない。したがって、事例Ⅲでは、甲に、Xに対する殺人既遂罪は成立しない。

4 正しい

Bの見解は、責任能力を欠いた状態で行われた結果行為を実行行為と捉えつつ、責任能力は意思決定時に存在すれば足り、必ずしも実行行為時に存在することは必要ないとする見解（結果行為説）である。Bの見解によると、事例Ⅰにおける、乙を殺害する行為（結果行為）が実行行為となる。そして、Bの見解によれば、責任能力は意思決定時に存在すれば足りるので、甲がX宅に赴いて同人を殺害しようと決意した時点で責任能力がある以上、39条1項の適用が排除される。したがって、Bの見解によれば、事例Ⅰでは、甲に、Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。

5 正しい

Bの見解は、責任能力を欠いた状態で行われた結果行為を実行行為と捉えところ、事例Ⅱの甲は、X宅には赴かず、Xの殺害には及ばなかったため、殺人罪の実行の着手がない。したがって、Bの見解によれば、事例Ⅱでは、甲に、Xに対する殺人未遂罪は成立しない。